

1500433-73.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Comarca: Viradouro

Foro: Foro de Viradouro

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHIAN HENRIQUE BOVO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Viradouro

Foro de Viradouro

Vara Única

Rua José Borelli, 10, Viradouro - SP - cep 14740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença nos autos sob o n. 1500433-73.2021.8.26.0557 - lauda de SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500433-73.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHIAN HENRIQUE BOVO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Vistos e examinados os presentes autos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia RHIAN HENRIQUE BOVO, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que, na noite de 13 de agosto de 2021, por volta das 20h32, na Rua Horaldo Langanke Pedro, altura do nº 241, Bairro

Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Terra Roxa, nesta comarca, ele trazia consigo, para fins de tráfico, 6,72 gramas de crack, armazenados em 73 segmentos plásticos transparentes, e 5,85 gramas de cocaína, acondicionados em 31 tubos plásticos, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (f. 01/05) e lhe foi concedida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, conforme decisão de f. 34/36.

Ante o descumprimento das medidas impostas, foi decretada a prisão preventiva do acusado (f. 100/101).

O acusado foi notificado (f. 132) e apresentou defesa preliminar (f. 135/136).

A denúncia foi recebida no dia 11 de maio de 2022 pela decisão de f. 137/139 e o réu foi citado (f. 163).

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas e, por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, admitida a incidência da causa de diminuição de pena.

A Defesa, por sua vez, destacou a confissão do acusado, tanto na fase de inquérito como na fase judicial, e pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06..

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha LUIS HENRIQUE DA SILVA, policial militar, ouvido na fase de inquérito (f. 02), declarou: "Em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora, quando adentramos a Rua Augusto Malaquias Machado, avistamos alguns indivíduos na esquina da Rua Horaldo Langank Pedro, sendo que, ao avistarem a viatura, saíram correndo, onde a equipe visualizou o indiciado Rhian dispensando algo em um entulho, logo de imediato realizamos abordagem do indiciado e ao verificar o que ele havia dispensado, logramos êxito em localizar trinta e um pinos de cocaína e setenta e três pedras de crack, indagado Rhian a respeito da droga, o indiciado confirmou que era sua e que estaria assumindo a "função" naquele horário, recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas conforme a Súmula Vinculante 11, para proteção de si próprio e de terceiros".

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento quando visualizaram indivíduos na esquina de duas ruas; ao perceberem a presença policial, saíram correndo; a equipe conseguiu abordar o acusado; foi possível ver ele dispensando algo no entulho; ao verificar o que era, encontraram drogas, especificamente cocaína e crack; o acusado admitiu informalmente que estava assumindo a função do tráfico naquele local; o acusado era conhecido dos meios policiais; em 24/12/2020, o acusado fugiu da viatura e capotou seu veículo; foram encontrados no veículo 14 eppendorfs de cocaína; o acusado lançou a droga em um entulho e umas tábuas; a droga estava em saquinhos; esses saquinhos não estavam dentro de qualquer recipiente; havia uma outra pessoa distribuindo drogas para mais pessoas, mas não conseguiram capturá-la; foi fácil perceber o que foi arremessado; o acusado não explicou por quanto tempo estava traficando; não se recorda se foi apreendido dinheiro ou anotação.

A testemunha LUCAS IZAIAS DOS SANTOS, policial militar, ouvido na fase investigativa (f. 03), relatou: "A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, quando adentramos a Rua Augusto Malaquias Machado e avistamos os indivíduos já conhecidos nos meios policiais pela Rua: Horaldo Langank Pedro, os indivíduos ao avistarem a viatura policial se evadiram, o indivíduo Rhian foi visto dispensando algo em um entulho, a equipe logrou êxito em abordá-lo e o que ele havia dispensando constatou-se tratar-se de trinta e um pinos de cocaína e setenta

e três pedras de crack, indagado o indiciado, este disse que a droga era de sua propriedade. O indiciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial. Fizemos uso de algemas conforme a Súmula Vinculante”.

Em juízo, disse que, no dia dos fatos, faziam patrulhamento; em determinada rua, viram, na esquina, um grupo de pessoas; essas pessoas saíram correndo ao avistarem a viatura; identificaram o acusado com algo na mão; ele dispensou esses itens próximo na esquina; fizeram a abordagem; localizaram o que o acusado havia jogado; era um saco plástico com 31 pinos de cocaína e 73 pedras de crack; o depoente conseguiu visualizar que o item arremessado era exatamente esse saco plástico, não seria possível confundir; viram o acusado dispensar e efetuaram a abordagem; é um local conhecido pelo tráfico de drogas; o acusado era conhecido dos meios policiais; confrontado, o acusado confessou que estava “na função”, ia começar a comercializar; não foi apreendido dinheiro ou anotação.

O acusado, perante a autoridade policial (f. 04), respondeu: “Não tenho advogado. Eu estava traficando lá, quando eu vi os policiais, dispensei a droga, sendo dois kits de cocaína e uns setenta crack. A cocaína era vendida a dez reais o pino, a pedra também era a dez reais. Fiz isso por falta de oportunidade, estou passando por dificuldades financeiras. Não ofereci qualquer tipo de resistência aos policiais militares. Não sofri qualquer tipo de agressão ou opressão policial”.

Em juízo, admite os fatos; disse que iria comprar um refrigerante e foi para a esquina; tinha acabado de pegar a droga; os policiais apareceram; o depoente dispensou a droga; ao descer a rua, os policiais o abordaram; o depoente iria vender essa droga; nessa época, estava desempregado e precisava de dinheiro, pois tinha acabado de ser demitido; não tinha comida em casa; tem 19 anos.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (f. 01), boletim de ocorrência policial (f. 06/07), auto de exibição e apreensão (f. 08), laudo de constatação provisória (f. 10/12), laudo de exame químico-toxicológico (f. 66/68), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Há confissão do acusado, mas referida prova não se encontra isolada nos autos. A prova testemunhal foi firme e coerente, está de acordo com o acervo documental e corrobora integralmente os fatos levados a conhecimento da autoridade policial, à vista do boletim de ocorrência lavrado.

O depoimento dos policiais militares deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado). Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre). Entretanto, no caso concreto, os policiais militares apresentaram versões firmes e coerentes entre si, cujas palavras não estão isoladas nos autos, mas, pelo contrário, respaldadas pelas demais provas. Ademais, não há notícia de conflito ou atrito entre acusado e policiais, seja prévio ou contemporâneo aos fatos. Por tais motivos, os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem elevado valor.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, portava droga e não o fazia com o elemento subjetivo específico de consumi-la, o que fica especialmente demonstrado pela confissão e pela quantidade significativa de drogas, sendo pouco crível que consumiria imediatamente aquela quantidade de substância apreendida. Ressalte-se que o acusado foi surpreendido com 6,73 gramas de crack acondicionados em 73 segmentos plásticos transparentes e 5,85 gramas de cocaína acondicionados em 31 tubos plásticos.

Ressalte-se que o fato de não ter restado demonstrado a efetiva venda da droga não afasta a tipicidade do delito. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

A culpabilidade é normal à espécie. O sentenciado não registra maus antecedentes. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social do sentenciado. Não é possível aferir, quer em sentido técnico ou em sentido vulgar, a personalidade do sentenciado. O motivo da conduta não é especialmente censurável, não sendo senão ínsito ao crime e, portanto, já valorado pelo legislador no momento da criminalização primária. As circunstâncias são próprias do tipo penal, não sendo especialmente reprováveis. As consequências não são especialmente graves. Não há vítima específica e, portanto, o comportamento da vítima não é elemento aplicável ao delito em apreciação. A natureza das drogas não socorre ao acusado e mereciam ser valoradas negativamente, contudo, a fim de evitar bis in idem deixo para valorar tais circunstâncias na terceira fase da dosimetria da pena. Por fim, a quantidade de droga não excede à normalidade das apreensões nesta comarca. Não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável, a pena permanece no valor mínimo legal, qual seja 5 ano(s), 0 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

O acusado é primário, conforme certidões de f. 78 e 79-80. O acusado tinha menos de 21 anos à época dos fatos e faz jus à atenuante respectiva. O acusado confessou o crime e faz jus à atenuante respectiva. Excepcionalmente, entendo que não é caso de aplicação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que não é possível desprezar a existência de duas atenuantes, sendo uma delas preponderante (confissão), sem que haja grave violação ao princípio da isonomia e individualização da pena. Com efeito, entendo que, em casos como este, aceitar que a pena possa, na segunda fase da dosimetria da pena, ser levada aquém do mínimo legal, é medida tributária da lealdade e boa-fé processual objetiva. Ao fazê-lo, observo a lição de RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR:

Uma atenuante, porém, quando se somar a circunstâncias judiciais todas favoráveis ao réu, não pode deixar de ser considerada pelo juiz, por uma exigência do princípio da lealdade. Refiro-me à atenuante do art. 65, III, d: 'ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime'. Feita a advertência pelo juiz, no interrogatório, de que a confissão espontânea será causa da atenuação da sua pena, o fato de o réu confessar a autoria do delito e assim fornecer elemento para a sua condenação (que poderia não acontecer à falta de outras provas) cria uma situação irreversível, a exigir do juiz – que usou da confissão para fundamentar a condenação – manter a promessa feita pela lei de que sempre seria atenuada a pena do réu que confessasse espontaneamente a autoria do delito. O princípio da boa-fé objetiva, que preside o sistema jurídico e exige de todos um comportamento leal, aplica-se também no âmbito do Direito Penal, a regular as relações do Estado com o réu no processo. (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Aplicação da Pena. Porto Alegre: Escola Superior da Magistratura da AJURIS, p. 49). Portanto, atenuo a pena e fixo a pena-provisória em 4 ano(s), 2 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

O acusado é primário. Não registra maus antecedentes. Não há prova que integre organização criminoso e, ao que consta, envolveu-se com a traficância em episódio

isolado, não se dedicando a atividades criminosas. Portanto, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11343/06. Embora a quantidade de droga não seja surpreendente, a natureza de ambas drogas é das mais lesivas e com alto poder de drogadição, de modo que mostra-se proporcional dosar a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos). Com tais considerações, fixo a pena definitiva ao acusado em 2 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 250 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Possível a fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direito. E isto porque o Supremo Tribunal Federal entende, por seu Plenário, ser inconstitucional o regime inicial necessariamente fechado (HC n. 11840). No mesmo sentido, julgou inconstitucional a vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos a que se refere o art. 33, § 4º e o art. 44 da Lei n. 11343/06 (HC n. 97256). Por esse motivo, o Senado Federal editou a Resolução n. 05/2012/RSF, suprimindo a proibição à substituição por penas alternativas.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime aberto.

Houve prisão cautelar no curso do processo. A segregação cautelar durou 0 ano(s), 2 mês(es) e 16 dia(s), de modo que resta cumprir uma pena privativa de liberdade correspondente a 2 ano(s), 3 mês(es) e 14 dia(s) de reclusão.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade. Em face do montante da pena aplicado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos devidos ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Viradouro, mediante depósito que deverá ser feito necessariamente em dinheiro na conta-corrente n. 130.219-1, agência n. 2777-4 (Viradouro), Banco do Brasil, vinculada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), CNPJ n. 08.491.687/0001-1.

A substituição da pena privativa de liberdade é mais benéfica e, por isso, prejudica a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou da vítima nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa.

Da detida análise dos autos e à luz do art. 316 do Código de Processo Penal, extrai-se que deve ser modificada a situação processual do(a) sentenciado(a). Considerando o patamar da pena e regime inicial fixados na sentença; considerando, também, que o crime ao qual foi condenado foi praticado sem violência ou grave ameaça; considerando, ainda, o encerramento da instrução criminal, de modo que não se justifica a manutenção da segregação cautelar para sua tutela; e considerando, por fim, o tempo de prisão preventiva ao qual já se submeteu o acusado, entendo que não mais subsistem os motivos que, na origem, determinaram a medida extrema da prisão cautelar. Não vislumbro risco, quer à ordem pública, quer à aplicação da lei penal, na autorização ao acusado para que aguarde eventual recurso e o trânsito em julgado em liberdade.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado RHIAN HENRIQUE BOVO, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 ano(s), 6 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão em regime inicial aberto e à pena de multa de 250 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a seguir

especificadas: (i) prestação de serviço a entidade beneficente local, a ser definida oportunamente; e (ii) prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos devidos ao Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Viradouro, mediante depósito que deverá ser feito necessariamente em dinheiro na conta-corrente n. 130.219-1, agência n. 2777-4 (Viradouro), Banco do Brasil, vinculada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), CNPJ n. 08.491.687/0001-1.

REVOGO a prisão preventiva. Expeça-se, de imediato, alvará de soltura clausulado. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

(a) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

(b) Caso exista pena de multa, certifique a Secretaria a existência de fiança nos autos, a qual deverá ser aproveitada para o pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, caso não concedida a gratuidade da justiça. Não havendo, ou havendo débito remanescente, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público, na forma do art. 480 das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça, observando-se a desnecessidade de intimação do(a) condenado(a) para pagamento da pena de multa nos autos do processo de conhecimento (CGJ, Processo n. 2014/75969, Parecer n. 108/2022-J);

(c) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

(d) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

(e) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

(f) Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Viradouro, 26 de maio de 2022.

PEDRO HENRIQUE ANTUNES MOTTA GOMES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA